

0012710-67.2021.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Pereira de Castro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... conhecido pela prática de crime de tráfico de drogas, visando coibir a mercancia espúria.

Foram ainda informados quanto à dinâmica do tráfico, bem como quanto as características dos agentes, pois a traficância estava sendo realizada por dois indivíduos, um trajando uma camiseta escura com logotipo da NIKE e uma bermuda preta e branca, e o outro vestindo um moletom de cores ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0012710-67.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012710-67.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER SANTANA FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

WAGNER SANTANA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, e do artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, segundo narra a denúncia, no dia 16 de junho de 2020, por volta da 09h30min, em período de calamidade pública, na Rua Piava, n. 14, Favela, nesta cidade e comarca de São Paulo, associou-se com outros dois indivíduos (Rafael e Alessandro) para a prática de tráfico de drogas, e ainda, traziam consigo, transportavam, expunham a venda, guardavam, mantinham em depósito, para entrega a terceiros, 344 (trezentos e quarenta e quatro) porções de cocaína, com massa líquida de 309,3 gramas, e 170 (cento e setenta) porções de crack, com massa líquida de 30,4 gramas, em desacordo e sem autorização legal ou regulamentar.

O réu não localizado para notificação pessoal (fl. 220), tendo sido notificado por edital (fl. 258). Decorrido o prazo da citação editalícia, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. Após, o réu habilitou-se nos autos (fls. 457/458) e o processo retomou seu curso (fl. 465). Defesa prévia a fls. 483/490.

Em instrução foram ouvidas quatro testemunhas.

Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesas formulou pedido de absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

Denúncia PROCEDENTE, em parte.

Segundo consta da denúncia, na data dos fatos, policiais civis, previamente cientificados, rumaram para o local dos fatos, notoriamente conhecido pela prática de crime de tráfico de drogas, visando coibir a mercancia espúria.

Foram ainda informados quanto à dinâmica do tráfico, bem como quanto as características dos agentes, pois a traficância estava sendo realizada por dois indivíduos, um trajando uma camiseta escura com logotipo da NIKE e uma bermuda preta e branca, e o outro vestindo um moletom de cores branca e cinza e uma calça escura, os quais alternavam na venda do entorpecente: ora um permanecia com dinheiro, ora com a droga e vice-versa.

Um terceiro indivíduo, usando um moletom cinza, calça escura e tênis branco, se encarregava de atuar como "olheiro", avisando a chegada da Polícia.

Os policiais se dividiram em duas equipes; os policiais Denis e Sergio incursionaram pela Rua Piava, enquanto os policiais João Paulo e Marcos adentraram pela Rua Paulo Frontim (continuação da Rua Barro Duro). Durante a incursão feita pela Rua Piava, Denis e Sergio visualizaram dois indivíduos em típica movimentação de tráfico de drogas, sendo certo que um dos indivíduos trazia consigo um estojo do tipo escolar, na cor cinza. Feita a verbalização, notaram um terceiro indivíduo que estava mais à frente o qual gritou: "suju é a Polícia". Em seguida, correu pela única rota de fuga, indo ao encontro dos policiais João Paulo e Marcos, os quais detiveram o indivíduo em questão, identificando-o como o réu WAGNER SANTANA FERREIRA. Os dois indivíduos que não conseguiram correr e atuavam na venda de drogas foram identificados, sendo o réu RAFAEL PEREIRA DA SILVA, o qual trazia consigo o estojo escolar, onde foram achadas diversas porções de drogas, tais quais 70 eppendorfs contendo Crack e 29 trouxinhas plásticas contendo cocaína, bem como R\$ 70,00 em notas trocadas; e o réu ALESSANDRO DOMINGOS JUNIOR, o qual trazia consigo R\$ 433,00 em notas trocadas.

O acusado RAFAEL acabou por admitir a participação no crime de tráfico, levando os policiais até um barraco, onde disse ser sua moradia. O imóvel ficava bem próximo ao local da abordagem inicial, em uma viela sem descrição. Franqueou a entrada e apontou o local, dentro de um forno, onde guardava entorpecentes. Ademais, dentro do eletrodoméstico, em minuciosa revista, também foi encontrada uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Taurus, com numeração suprimida e municada com 6 cartuchos íntegros, além de uma sacola plástica onde estavam guardados outros 22 cartuchos íntegros e 06 cartuchos deflagrados. No imóvel também se encontrava a genitora de RAFAEL, no entanto, em razão do acusado ter reivindicado a propriedade da droga e da arma localizada não foi conduzida à delegacia.

A materialidade quanto aos crimes encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos (fls. 303/305 e 334/336), de forma a estabelecer perfeita correlação entre o material apreendido, aquele submetido à avaliação preliminar (fls. 15/18 e 19/22) e, finalmente, o exame toxicológico. Vale destacar, pois, que a cadeia de custódia está preservada, afastando, portanto, a alegação trazida pela defesa de ambos os acusados.

Induvidosa, ainda, a autoria delitiva.

O policial civil Denis Alves da Silva disse que, na data dos fatos, de posse de informações angariadas com trabalho de campo, rumaram ao local dos fatos, próximo, inclusive, do distrito policial. Ficou em companhia do policial Sérgio. Tinham as características de vestuário e físicas dos vendedores e sabiam quais eram os pontos de fuga do local, motivo pelo qual se dividiram em duas equipes. Ao adentrarem no local, detiveram ALESSANDRO e RAFAEL. Outro, que saiu correndo, foi detido pela outra equipe, sendo o acusado WAGNER. WAGNER saiu correndo e gritava "polícia, polícia". ALESSANDRO e RAFAEL foram imediatamente abordados, tão logo avistados. Com eles encontraram as drogas e dinheiro. Depois, com os outros dois policiais, foram até o local indicado por RAFAEL, sua casa, onde encontraram mais drogas,

escondidas no fogão e, no guarda-roupas, um revólver também foi apreendido. Quem fez a revista em ALESSANDRO e RAFAEL foi o policial Sérgio, permanecendo a testemunha na segurança da equipe. Sabe dizer da apreensão, no local da prisão, de cocaína e crack. Todos assumiram que estavam na traficância, ainda no local, embora no distrito tenham mudado essa versão. As informações de que dispunha eram originárias de um morador do local, passadas para a chefia da investigação, que na data do fato era sua. Foi o único contato pessoal que teve com este informante. Depois do recebimento destas informações, averiguaram preliminarmente a existência de traficância no local e, cerca de uma semana depois fizeram a incursão. As características passadas pelo informante foram confirmadas, no dia da prisão, com o informante, por telefone. Este informante, no dia da incursão, passou as características de vestuário dos traficantes, as roupas que os traficantes estariam usando naquele exato dia. Não se recorda, exatamente, quem localizou a arma, mas lembra-se que foi encontrada dentro de um guarda-roupa. Provavelmente foi o responsável por pegá-la neste móvel.

No mesmo sentido o quanto narrado pelo policial civil Sérgio Otavio dos Santos, ratificando o quanto antes dito pelo seu companheiro Denis.

Lembra-se da apreensão de drogas, numa pochete, com RAFAEL, e a maior parte do dinheiro com ALESSANDRO. Outra equipe foi responsável pela detenção do "olheiro", WAGNER. Foi o responsável pela revista pessoal de ALESSANDRO e RAFAEL. Não se recorda quem achou a arma no interior da casa, pois permaneceu na segurança na parte

externa, ingressando apenas posteriormente, "quando a coisa já estava mais tranquila".

Recorda-se, inclusive, que a mãe de RAFAEL acompanhou toda a busca. Segundo Denis disse, a arma foi encontrada num guarda-roupa.

Já policial civil João Paulo dos Santos Mattos disse que foram à comunidade do Barro Duro, em duas equipes, cada qual entrando por um lado daquela favela. Estava junto com o policial Marcos. Entraram e escutaram uma correria, com pessoa gritando sobre a presença da polícia. Uma pessoa corria em direção à testemunha, sendo abordada. Outros estavam abordados em outro local, com entorpecentes apreendidos. A testemunha e seu parceiro detiveram o olheiro. Depois, foram até uma casa indicada pelos traficantes onde, além de drogas, encontraram arma e munições. Não acompanhou a revista de ALESSANDRO e RAFAEL. Capturaram WAGNER. WAGNER disse que era o "olheiro" da biqueira. Na residência, que era do acusado RAFAEL, encontraram a arma e munições, além de drogas. Ele, RAFAEL, disse que as drogas eram dele; na delegacia, ele disse que pertenceriam a outra pessoa, David ou Davi, pelo que se recorda. O policial Denis já investigava a traficância no local, e foram prestar-lhe apoio, nesta data, em vista das circunstâncias de local, com muitas rotas de fuga. Por isso, duas guarnições policiais entraram por pontos distintos. Não se recorda o que foi dito por ALESSANDRO no momento da prisão.

O policial civil Marcos Paulo da Silva disse que acompanhou o policial João Paulo, ratificando, em suma o quanto dito por ele, notadamente quanto ao fato de WAGNER servir como "olheiro" daquele ponto de venda de drogas. Confirmou também a apreensão de drogas e arma com os acusados ALESSANDRO e RAFAEL. Não ingressou na residência, permanecendo na parte externa, na segurança da equipe. Sabe, contudo, da localização de mais drogas, com as mesmas características de embalagem daquelas apreendidas na "biqueira", além da arma. Essa investigação partiu do policial Denis, que iniciou as apurações da traficância no local, sendo que foram prestar-lhe apoio na incursão.

Interrogado, Alessandro permaneceu em silêncio.

Rafael confessou o fato e disse não conhecer o réu Wagner.

O réu, intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tornando-se revel.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova amealhada basta para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A prova oral colhida indica que o réu, juntamente com Alessandro e Rafael, foi flagrado em poder de significativa quantidade de drogas, separadas em porções

individuais. Ademais, em poder deles estava, além dos entorpecentes, dinheiro em notas de pequeno valor, típico da venda de drogas. O réu exercia a função de “olheiro”, tanto que quando avistou os policiais no local gritou que a polícia estava no local.

Por outro lado, a alegação comum da defesa, de ser necessária a exclusão dos depoimentos de testemunhas, por serem policiais, não procede.

O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção juris tantum de agir escorreitamente, presumindo-se ser legítima a sua atuação, sendo certo que como qualquer pessoa, pode ser testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade. Até mesmo porque o policial “deve no exercício das funções (e depor sobre suas ações constitui parte de seu mister) igualmente dizer a verdade, só não merecendo consideração se os indícios constantes dos autos o contrário revelem...” (TJSP Ap. Crim. 177.083-3/6).

Por estes motivos a simples condição de policial, conforme reconhece a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha impedida ou suspeita.

Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para sua suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende. Sendo, portanto, o depoimento policial plenamente válido, não podendo ser, aprioristicamente, desconsiderados em razão da condição de policial, máxime quando não contraditados em Juízo, o que serve de indício da lisura de sua atuação, afasta-se a alegação de falta de validade.

No ponto, vale acrescentar que as declarações foram firmes, especialmente dos policiais Denis e Sérgio, responsáveis por deter o réu.

Confirmaram a apreensão da droga e do dinheiro em poder dos acusados, bem como a localização da arma na residência de Rafael. Eventuais falhas de memória ou confusões marginais não desautorizam, tampouco podem contaminar em absoluto a narrativa de todas as testemunhas, especialmente quando harmônica, coerente e firme, de maneira geral. Ademais, o lapso temporal entre o flagrante (junho de 2020) e o momento da instrução processual, justifica a perda de fragmentos de parte das memórias, especialmente em ocorrência que, lamentavelmente, como cediço, é corriqueira.

Por outro lado, cabe destacar que a imputação do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 não pode subsistir no presente caso. Pois, ausentes provas suficientes nos autos capazes de comprovar a habitualidade da união entre os réus com ânimo associativo para o fim de praticar os crimes previstos no artigo 33 da mesma Lei. Não restou comprovada de forma cabal a prévia e duradoura associação para o tráfico de entorpecentes, não pode ser imposta condenação, mormente quando baseada apenas em conjecturas. Isso porque, “três são os requisitos básicos: um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a concretização de um programa delinquencial” (ALBERTO SILVA FRANCO, apud DAMÁSIO E. JESUS, “Lei Antidrogas Anotada”, 10ª ed., 2010, p. 177.).

Entendimento esse conforme, inclusive, àquele do C. STJ (Jurisprudência em Teses, Boletim n. 45: Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência.).

No caso, há apenas o flagrante do réu com mais dois indivíduos no comércio Espúrio, sem vínculo de permanência, o que é insuficiente para a condenação pelo tipo em comento.

Assim, a denúncia procede parcialmente.

Passa a fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, pois o réu traficava cocaína na forma de crack, o que indica, exatamente, maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente tem grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, sendo que pode, inclusive, viciar no primeiro uso. Na verdade tal entorpecente tornou-se o grande mal social dos tempos presentes,

como qualquer pessoa que habite os grandes centros urbanos pode ver, todos os dias, na legião de infortunados que vagam pelas ruas, colocando em risco a segurança de toda coletividade, pela necessidade de manutenção do vício e da dependência. E tal circunstância não se cuida, como geralmente argumentado, de mera opinião pessoal do julgador, mas fato concreto, público e notório, assim reconhecido pelos meios científicos e midiáticos. Cuida-se, na verdade, do maior problema de saúde pública do país, reconhecem os especialistas em saúde pública.

Segundo entendimento firmado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, a natureza, qualidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos podem ser utilizados, como critério de fixação das penas, seja no estabelecimento daquela inicial (artigo 42), seja para o cálculo do fator de redução das reprimendas a serem impostas (artigo 33, parágrafo quarto), vedada, em todo caso, a utilização concomitante nestas ocasiões (Informativo 733, Plenário).

“Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto”, já afirmou o C. Supremo Tribunal Federal (HC 107.274, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12.04.2011, com grifos nossos).

Assim, as penas iniciais partem de 06 (seis) anos de reclusão, com pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase, incabível o agravamento em razão da calamidade pública da Covid-19, pois esta não foi determinante para a consumação do delito.

Na terceira fase, cabível a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Prescreve o dispositivo:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

De rigor a aplicação da causa de diminuição, pois não se demonstrou, durante a instrução processual, que o acusado se dedicasse a atividades criminosas, tendo o fato se caracterizado como excepcional.

Assim, reduzo a pena em 2/3 e estabeleço a pena final em 02 (dois) de reclusão e no pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Fica estimado o dia-multa no patamar básico ante a parca condição econômica da ré.

Fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44, caput, do CP e verificando-se que as medidas são socialmente recomendáveis, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, nos termos do artigo 46 do mesmo diploma, em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Criminais, descontado eventual período de custódia cautelar, e prestação pecuniária à entidade social no valor de um salário-mínimo.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Lei n. 11.343/06 que proíbe expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256. Neste prisma: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIMENTO. DECISÃO BASEADA, APENAS, NA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 44 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. PENA. REGIME. LEI 8.072/1990. DISPOSITIVO QUE IMPUNHA O REGIME FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.

INCONSTITUCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I – Não obstante a vedação prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006, o Plenário desta Corte,

ao apreciar o HC 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico, por ser incompatível com os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. II - Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo de que o magistrado de primeiro grau, caso entenda necessário, fixe, de forma fundamentada, uma ou mais de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III - Concessão da ordem de ofício para determinar ao juízo de piso que: i) superada a obrigatoriedade de imposição do regime fechado aos condenados por tráfico de drogas, avalie se o paciente preenche os requisitos para a fixação do regime aberto, ou, caso entenda pela imposição de regime mais grave do que o previsto para o quantum de pena, que o faça de forma fundamentada, e ii) afastado o óbice à conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, analise se o paciente preenche os requisitos para a referida substituição. (HC 114029-SP - Rel. Ricardo Lewandowski - j. 18.02.2012 - DJe 22.02.2013). Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça admite tal substituição, inclusive o regime aberto de cumprimento de pena, conforme julgados: STJ - HC184497-SP - Rel. Jorge Mussi - j. 07.02.2013 - DJe 19.02.2013 e HC 216197-RS - Rel. Laurita Vaz - j. 07.02.2013 - DJe 18.02.2013.

Considerando o regime inicial aberto, o réu poderá apelar em liberdade.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o réu WAGNER SANTANA FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) de reclusão, em regime inicial aberto, e no pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Absolvo o réu do delito do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, fazendo-o nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Concedo o apelo em liberdade, considerando o regime inicial de cumprimento de pena. Revogo a prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas e da taxa judiciária, na forma da lei.

P.R.I.C

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA